

1500815-75.2021.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... envolvimento pretérito somente com tráfico de entorpecentes (fls. 43/46).

Ainda que a situação tenha causado efetivo temor nas menores, o que parece incontroverso e até presumível, o temor se origina da própria situação em si, de se deparar com invasores dentro de sua residência, e não de efetiva ação do agente em ameaçar, de maneira dolosa, as vítimas. Não verifico o necessário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500815-75.2021.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500815-75.2021.8.26.0457

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177419/2021 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA, 18812328 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 523/21/808 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 2177419 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTHUR ALCINDO MONTEIRO DE CARVALHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

VISTOS.

ARTHUR ALCINDO MONTEIRO DE CARVALHO e GABRIEL JUNIO MEIRELES MÁXIMO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, "caput" cc. §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 1º de julho de 2021, por volta de 01h20min, nesta cidade, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça - exercida com o emprego de arma branca em face das menores Eliana Dalliessi da Silva (13 anos) e Vitória Dalliessi da Silva (10 anos) - coisas alheias móveis - consistentes em uma televisão da marca "Semp Toshiba", de 32" polegadas, bem como em uma blusa de moletom sem marca pertencentes a Valquíria Aparecida Dalliessi.

Narra a denúncia, segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo indicadas, ARTHUR e GABRIEL, previamente ajustados, na posse de uma arma branca, ingressaram na residência das vítimas e se depararam com as menores Eliana e Vitória na sala da habitação. GABRIEL, que levava consigo a arma branca, ameaçou as irmãs Eliana e Vitória exibindo o instrumento e ordenou-lhes que ficassem quietas, enquanto ARTHUR subtraía a televisão que guarnecia a sala e o moletom. Após se apoderarem dos produtos do roubo, GABRIEL e ARTHUR deixaram o local, enquanto Eliana e Vitória correram assustadas até o quarto dos pais e narraram todo o ocorrido. Valquíria - mãe de Eliana e Vitória -, na companhia do marido e de alguns vizinhos, conseguiu apurar que ARTHUR era um dos autores do roubo à sua residência e o localizou. Conquanto ARTHUR negasse a prática do roubo, quando encontrado e confrontado pelas vítimas, o agente vestia o moletom que foi roubado da casa de Valquíria, bem como indicou o terreno onde estava depositada a televisão subtraída. A polícia militar foi acionada e ARTHUR foi autuado em flagrante.

Os trabalhos de investigação prosseguiram e apurou-se que o comparsa de ARTHUR na consecução do roubo foi GABRIEL. Tanto ARTHUR quanto GABRIEL foram reconhecidos fotograficamente em solo policial como os autores do roubo em tela. A arma branca utilizada pelos agentes foi abandonada no local dos fatos e apreendida.

Recebida a denúncia em 20/07/2021 (fls. 192), seguiram-se citação e oferecimento de defesa prévia (fls. 204 e 213).

Durante a instrução, foi ouvida uma vítima e os réus foram interrogados, tendo lugar os debates, nos quais o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação; disse que a materialidade é incontroversa; Arthur confessou parcialmente a autoria, narrando um furto, e não um roubo; Gabriel foi reconhecido por fotografias; os réus são multirreincidentes e não fazem jus aos benefícios legais, tampouco recurso em liberdade. A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição de Gabriel; sobre Arthur, o reconhecimento das atenuantes de confissão e minoração das consequências do crime, bem como a desconsideração do concurso de agentes e uso de arma branca.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de exibição e apreensão de fls. 18, auto de entrega (fls. 19), auto de avaliação (fls. 71) e boletim de ocorrência (fls. 10/13). Frise-se ainda que durante o inquérito policial, houve reconhecimento fotográfico (fls. 20/25).

Em juízo, a testemunha Valquíria, mãe das crianças vítimas diretas do ilícito, disse que o réu Arthur é conhecido no bairro e, logo após o roubo, teria sido parado por populares a poucas ruas de distância do local dos fatos; foi até o local com seu marido, que conhece o réu; o réu teria confessado o roubo e, inclusive, indicado o local onde teria guardado a televisão, em um terreno, o que se confirmou; seu marido reconheceu o réu Arthur com facilidade pois ele estava vestido com o moletom roubado de sua residência, bastante característico, pois de um clube de futebol onde ele joga; Valquíria teria tido uma conversa com o réu Arthur na frente da casa da avó deste, onde ele pediu desculpas por ter realizado o roubo; a avó de Arthur presenciou tal conversa; não teve qualquer contato com Gabriel e não o conhece; disse que suas filhas realizaram o reconhecimento fotográfico em solo policial, porém, disse que com relação a Gabriel era 'muito diferente das fotos'.

Embora Arthur tenha negado o ilícito em solo policial (fls. 07), em juízo, mudou completamente a narrativa anterior. Arthur disse que na data dos fatos estava sob o efeito de entorpecentes; confessa ter subtraído a televisão e a blusa, porém nega qualquer violência ou ameaça; diz que não viu ninguém dentro da casa; o portão

estava aberto; usou a faca tão somente para cortar os fios da televisão; evadiu-se e se escondeu em um terreno, onde depositou o bem subtraído; foi então encontrado por 'Dan', marido de Valquíria e pai das crianças vítimas diretas, que o agrediu e exigiu que ele informasse o local onde a televisão estava; disse que estava 'louco de drogas'; disse que estava sozinho, não tendo Gabriel participado do ilícito; reforçou que não viu nenhuma criança no local dos fatos; confessou que praticou outros furtos na mesma noite; confrontado sobre o relato de sua vó, que disse que o próprio Arthur teria confessado que estava na companhia de Gabriel, disse que ela se confundiu, que ele jamais afirmou isso, sendo que ela presumiu tal dado, pois ambos de fato se conheciam e usavam drogas juntos.

Como se vê de seu depoimento, Arthur confessa parcialmente o ilícito, pois narra a prática de um furto, e não um roubo.

Além disso, todo o conjunto probatório confirma sua autoria, posto que foi localizado pouco tempo após o delito com a blusa subtraída e, também, soube apontar onde estaria a televisão; não fosse ele o autor, não saberia tal informação. Isso tudo, aliado à confissão parcial em audiência, conduz a inequívoca convicção de sua culpa.

Sobre a correta tipificação do delito, penso que o quanto aventado por Arthur em sua autodefesa merece acolhimento.

Diante do processado, não me convenço da ocorrência de violência ou grave ameaça, elementares do tipo penal capitulado na denúncia.

É que Valquíria sustentou, de maneira firme e segura, que Arthur e a possível pessoa que o acompanhava na empreitada ilícita não ameaçaram suas filhas. Um dos criminosos teria, tão somente, ordenado que as crianças ficassem quietas ou feito sinal de silêncio com o dedo indicador frente aos lábios.

Embora o agente de fato portasse uma faca, o que restou incontroverso e confesso, a prova coligida indica que a arma não foi utilizada, em nenhum momento, com o intuito de constranger as vítimas. Da prova dos autos, convenço-me tão somente de que os agentes intentaram a prática tão somente de furto, principalmente pelas notícias - e também confissão do réu - de que teria praticado diversos furtos anteriormente, na mesma noite.

Inclusive, os antecedentes de Arthur não dão conta de que ele tenha propensão à prática de crimes violentos - possui envolvimento pretérito somente com tráfico de entorpecentes (fls. 43/46).

Ainda que a situação tenha causado efetivo temor nas menores, o que parece incontroverso e até presumível, o temor se origina da própria situação em si, de se deparar com invasores dentro de sua residência, e não de efetiva ação do agente em ameaçar, de maneira dolosa, as vítimas. Não verifico o necessário dolo de ameaçar, elementar do tipo, mas tão somente o dolo na subtração da coisa alheia, pelo que a conduta se amolda ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Nesse sentido:

ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - POSSIBILIDADE - AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. Cabível a desclassificação para o crime de furto quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por roubo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, ACR 0004345-88.2016.8.26.0635, Rel. Willian Campos, j. em 22/02/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO - POSSIBILIDADE - AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.

Cabível a desclassificação para o crime de furto quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por roubo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, ACR 1500600-65.2018.8.26.0567, Rel. Willian Campos, j. em 13/06/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO FURTO RECURSO NÃO PROVIDO. Agente que arrebatou a bolsa da vítima e correu do local. Ausente o emprego de violência ou grave ameaça, de rigor a desclassificação. (TJSP, ACR 0019323-52.2005.8.26.0604, Rel. Willian Campos, j. em 04/12/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

ROUBO SIMPLES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante preso em flagrante e que confessou parcialmente. Condenação mantida. Pedido subsidiário de desclassificação para furto simples. Necessidade. Subtração evidente. Emprego de grave ameaça que não foi suficientemente comprovado. Desclassificação necessária para furto simples, partindo da pena-base mínima e compensando-se integralmente a reincidência com a confissão espontânea. Regime inicial intermediário e indeferimento de substituição por alternativas, em razão da reincidência por crime de roubo. Apelo provido em parte para a desclassificação para furto simples, com penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial intermediário, mais 10 dias-multa. (TJSP, ACR 0002945-68.2018.8.26.0635, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em 18/12/2018, 16ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

FURTO SIMPLES (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO). Recursos bilaterais. MINISTERIAL. Pretendida condenação por roubo. Impossibilidade. Ausência das elementares da violência ou grave ameaça. Correta desclassificação. DEFENSIVO. Tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse, ainda que de forma efêmera. Inteligência da Súmula/STJ, nº 582. DOSIMETRIA. Redução do incremento na primeira etapa. Manutenção da agravante da calamidade. Penas diminuídas. Preservação das substituições do CP, art. 44 e do regime aberto no descumprimento. PROVIMENTO PARCIAL APENAS AO DEFENSIVO. (TJSP, ACR 1501555-41.2021.8.26.0616, Rel. Eduardo Abdalla, j. em 28/04/2022, 6ª Câmara de Direito Criminal) (grifos meus)

STJ Verificada a subtração da coisa móvel alheia, sem a ocorrência de grave ameaça ou violência a pessoa da vítima, como no caso, correta a decisão que desclassificou o crime de roubo para o de furto simples (RSTJ 87/385)

De rigor, portanto, com fundamento no artigo 383, caput, do CPP, a desclassificação da conduta para furto, nos termos do artigo 155, caput, do CP.

A situação de Gabriel, porém, é um tanto mais controversa.

Gabriel sustentou a versão dada em solo policial; disse que não conhece a vítima; negou a autoria dos fatos; não sabe como ou porque foi relacionado aos fatos; disse que a vítima e outras pessoas destruíram a casa de sua mãe após os fatos, por acreditarem no seu envolvimento, porém a vítima teria até mesmo se comprometido a ressarcir os danos por ele não estar de fato envolvido; conhece a avó de Arthur e com ela não mantém uma boa relação, posto que ela nunca aprovou a proximidade que Arthur e Gabriel tiveram no passado; acredita que ela possa querer incriminá-lo falsamente.

Diante da controvérsia instaurada, Valquíria foi ouvida novamente, tendo afirmado que Gabriel não é a pessoa da foto que suas filhas teriam reconhecido; disse também que não tem qualquer relação com a história de ressarcimento de danos e depredação de residência narrada por Gabriel, sendo que seguramente o réu se refere a fatos e pessoas diversas; disse, mais uma vez, que não houve ameaça com a faca.

Perceptível que o conjunto probatório é um tanto frágil.

Arthur afirma que agiu sozinho, e as vítimas sustentam que havia duas pessoas na residência.

A única informação que relaciona Gabriel aos fatos é o relato da avó de Arthur (fls. 88).

Gabriel diz, porém, que ela não nutre bons sentimentos por sua pessoa, em especial por conta de seu 'passado problemático', acreditando que ela possa querer incriminá-lo por tal razão.

Embora, vênia, eu não veja razões claras e concretas para se crer que Cleonice de fato intentasse incriminar falsamente Gabriel, imperioso apontar que existem outras fragilidades na prova produzida.

A primeira é que Cleonice não foi ouvida em juízo, razão pela qual a dúvida que seu próprio neto suscitou (de que não teria dito a ela que Gabriel estava consigo na data dos fatos) não foi objetivamente dirimida.

A segunda, e muito importante, é o reconhecimento fotográfico realizado (fls. 86/87).

É sabido que o próprio reconhecimento pessoal é de enorme controvérsia na jurisprudência e, principalmente, na doutrina, por conta de sua fragilidade probatória.

O reconhecimento fotográfico, então, é ainda mais questionável.

No caso, chama a atenção que as fotos foram levadas até a delegacia pela própria vítima Valquíria, mãe das menores; consta, dos autos de reconhecimento, que somente essas fotos teriam sido apresentadas para as menores que teriam presenciado o delito, sem a apresentação de outras fotos de pessoas diversas; além disso, e de vital importância, é que a própria Valquíria põe enorme dúvida sobre o reconhecimento fotográfico realizado, dizendo categoricamente que a pessoa da audiência (Gabriel) não é a mesma das fotos apresentadas.

Deve se considerar, ainda, que as vítimas são crianças, cujos reflexos negativos de terem presenciado o delito são notórios. Além disso, os fatos ocorreram em horário noturno.

Valquíria relatou que as crianças, meses após os fatos, ainda se assustavam bastante com qualquer barulho no portão da residência.

Nesse aspecto, inevitável trazer à discussão a possibilidade de falsas memórias ou distorções de memória.

Como se depreende da prova produzida, ao que consta, o reconhecimento fotográfico se deu por meio de técnica conhecida como show up, que consiste na exibição de somente um suspeito para que seja reconhecido. Tal sistemática é amplamente criticada por especialistas, visto que “expõe a vítima/testemunha à possível distorção de sua memória para o verdadeiro suspeito” (Ministério da Justiça. Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho Aplicados ao Reconhecimento Pessoal e aos Depoimentos Forenses. Lilian Stein coord. Pensando o Direito n. 59, p. 50).

A doutrina especializada aponta que crianças, em especial, estão mais suscetíveis ao fenômeno de distorções de memória:

“Como já referido, ninguém está imune a distorções de memória. Contudo, alguns tipos de pessoas são mais susceptíveis a estas distorções do que outras. Designadamente, crianças muito novas e pessoas idosas (mais de 65anos) parecem ser

mais vulneráveis às contaminações de memória acima descritas (Davis & Loftus, 2005)" (Ferreira, Mário Boto. Testemunhas Oculares e Distorções de Memórias. In: Silva, Evani Zambon Marques da; Saraiva, Rute; Ferreira, Mário Boto (coordenação científica). Direito e Psicologia. Lisboa: Coimbra Editora, 2013, p. 82).

Assim, não se trata de negar valor ou desacreditar na palavra das vítimas, mas sim, de especial cautela na valoração de tal prova, mormente quando se demonstra insegura e isolada.

Sobre o reconhecimento fotográfico e as falsas memórias, diz a abalizada doutrina:

"A influência de um reconhecimento e da palavra da vítima no campo do processo penal brasileiro precisa de atualização. Não se pode mais, ingenuamente, acreditar no que a boca diz alienadamente, porque em diversos países já se percebeu que a memória de testemunhos/vítimas oculares pode ser falível! A psicologia do testemunho dispensa um longo percurso teórico para tanto, demonstrando que o senso comum teórico parte de uma noção equivocada da memória como um arquivo, sem possibilidade de equívocos. Ubaldo Nicola (Parece mas não é. Trad. Maria Margherita De Luca. São Paulo: Globo, 2007, p. 46) aponta: 'A metáfora da memória como arquivo tem duas consequências inaceitáveis. A primeira é a passividade da memória no que diz respeito à recordação. No armazém mnemônico, deveriam ser metodicamente conservadas todas ou quase todas as recordações, sem diferenciação quanto à sua qualidade. Mas a memória não é absolutamente neutra: ela escolhe, seleciona, modifica. Assim como para a percepção, também para a memória vale a constatação fundamental deque percebemos apenas os resultados, e não o trabalho realizado pela mente para alcança-los. Trabalho que, no caso da memória, parece comparável ao de um diretor de cinema, baseado que está na função central da montagem, ou seja, da livre construção de um fio lógico ou narrativo entre elementos diversos (impressões perceptivas, falsas recordações, elaborações cognitivas,) A segunda consequência inaceitável diz respeito à separação estabelecida entre atividade específica da memória e o resto da mente. (...) a metáfora da memória/arquivo prevê uma arquitetura da mente com quartos separados (...) que hoje se mostra totalmente inadequada.' E arremata: 'Poderia parecer que aquilo que normalmente consideramos mera reprodução seja, em medida muito maior do que geralmente se admite, uma verdadeira construção, criada para justificar a impressão deixada pelo original. É exatamente essa impressão, raramente definida muito precisamente, o que mais facilmente persiste, e, enquanto os detalhes foram tais que possam ser construídos em torno dela de modo racional, a maior parte de nós fica bastante satisfeita e tende a pensar que recordou literalmente aquilo que na verdade reconstruiu. (...)'

No campo jurídico, mais especialmente no processo penal, sabe-se da falibilidade da prova testemunhal. Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007) demonstra: 'A prova testemunhal é o meio de prova mais utilizado no processo penal brasileiro e, ao mesmo tempo, a mais perigosa, manipulável e pouco confiável. Esse grave paradoxo agudiza a crise de confiança existente em torno do processo penal e do próprio ritual judiciário. (...) Entre as inúmeras variáveis que afetam a qualidade e confiabilidade da prova testemunhal, propomos um recorte pouco comum na doutrina jurídica: as falsas memórias. As falsas memórias se diferenciam da mentira, essencialmente, porque, nas primeiras, o agente crê honestamente no que está relatando, pois a sugestão é externa (ou interna, mas inconsciente), chegando a sofrer com isso. Já a mentira é um ato consciente, onde a pessoa tem noção do seu espaço de criação e manipulação. Ambos são perigosos para a credibilidade da prova testemunhal, mas as falsas memórias são mais graves, pois a testemunha ou vítima desliza no imaginário sem consciência disso. (...) Finalizando, há que despertarem o direito processual penal e os atores judiciais para esse grave problema que ronda a prova testemunhal, a palavra da vítima e os reconhecimentos, buscando apurar técnicas de interrogatórios que reduzam a indução e facilitem a identificação das falsas memórias." (ROSA, Alexandre Moraes da. Falsas Memórias. In: <http://alexandremoraisdarosa.blogspot.com.br/2010/03/falsas-memorias.html>) (grifos

meus)

Tourinho Filho já apontava, há anos, sobre a precariedade do reconhecimento como meio de prova:

“de todas as provas previstas no nosso diploma processual penal, esta é a mais precária. A ação do tempo, o disfarce, más condições de observar, erros por semelhança, a vontade de reconhecer, tudo, absolutamente tudo, torna o reconhecimento uma prova altamente precária. Não se deve olvidar que Penélope, esposa de Ulysses, não o reconheceu após alguns anos de sua ausência...” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, v. 1, ed. Saraiva, 1996, p. 381) (grifos meus)

Já decidi, também, a jurisprudência, que “o reconhecimento pessoal ou fotográfico é prova precária, pelo que se faz necessário que seja ela cercada de garantias, para aferição correta no caso concreto” (JUTACRIM 90/19).

Devo lembrar, ainda, o célebre e recente julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso em Habeas Corpus n. 206.846/SP, assim ementado:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 22/02/2022, SEGUNDA TURMA) (grifos meus)

Nesse cenário, tenho por bastante frágil o conjunto probatório com relação a Gabriel, que se resume a um único reconhecimento fotográfico realizado em desacordo aos ditames do artigo 226 do CPP e por duas crianças compreensivelmente abaladas pelo ilícito que presenciaram.

Para o decreto condenatório não bastam os indícios da autoria e prova da materialidade, mas tem que haver a certeza de que o réu praticou (seja como autor, coautor ou partícipe) o fato criminoso.

Por esse motivo a Lei Processual Penal prevê que as provas colhidas durante o Inquérito policial devem ser corroboradas pelas produzidas em juízo, caso contrário, não poderá haver condenação com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos em investigação (artigo 155, caput, segunda parte).

O aludido texto legal é complementado pelo artigo 386, incisos V e VII, o qual

dispõe sobre a impossibilidade de condenação caso não haja prova suficiente da autoria, consoante o princípio in dubio pro reo.

Assim, na dúvida, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

Nossa jurisprudência já decidiu que:

“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (RT 708/339).

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunho de certeza, a absolvição do réu se impõe” (RJTJSP 10/545).

E, in casu, não há certeza do envolvimento de Gabriel.

Desse modo, à luz da prova produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não há mesmo como se afirmar, com segurança, que o réu Gabriel tenha concorrido para a suposta infração penal narrada na denúncia, impondo-se sua absolvição.

Passo a dosar as penas de Arthur.

O réu é primário reincidente (vide processo 0000303-85.2015.8.26.0552, com trânsito em julgado em 05/02/20185) e possui maus antecedentes (vide processo 0000027-83.2017.8.26.0552)

A culpabilidade é normal, não cuidando o Ministério Público de provar o contrário. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n.217.819).

Presente uma única circunstancial negativa, adequado fixar a pena-base do delito um pouco acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A agravante da reincidência (art. 61, I, CP) é compensada pela atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP), não alterando a pena-base, portanto.

Todavia, presente ainda a agravante do artigo 61, inciso II, 'h', do CP, pois praticado o furto contra criança, devendo a pena ser exasperada em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 634.754/RJ).

Assim a pena provisória é fixada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Inviável o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, 'b', do CP, como pretende a defesa. Isso porque não houve qualquer espontaneidade de Arthur em indicar onde estava a res furtiva. Arthur na verdade se viu completamente acuado após ter sido pego por populares, tendo indicado o local onde se encontrava a televisão por medo, e não com o intento de minorar as consequências do crime.

Por fim, deve a pena ser aumentada em um terço por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, CP).



Assim, a pena definitiva do réu é de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Considerando o quantum de pena privativa de liberdade aplicada, as circunstanciais razoavelmente positivas, porém atento à reincidência do acusado, bem como o disposto no artigo 33, § 2º, 'b', e § 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena corporal seria o semiaberto; todavia, considerando o tempo de prisão preventiva já cumprido pelo acusado (mais de metade da pena), com fundamento no artigo 387, § 2º, do CPP, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal o aberto.

Reputo inadequada, porém, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu reincidente doloso (artigo 44, II, CP).

Em mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, encontrando óbice no art. 77, I, do CP.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, corrigido monetariamente desde então.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima (entendimento dominante no STJ).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu ARTHUR ALCINDO MONTEIRO DE CARVALHO pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 16 (dezesesseis) dias-multa, este último fixado no mínimo legal; e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER o réu GABRIEL JUNIO MEIRELES MÁXIMO, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se ordem de liberação de ARTHUR, que cumprirá o restante da pena em regime aberto, salvo se preso por outro processo.

Expeça-se alvará de soltura de GABRIEL.

Permito que o réu condenado recorra em liberdade, inexistindo os requisitos autorizadores da custódia cautelar, exceto se preso por outro processo, por óbvio.

Transitada em julgado esta, inclua-se o nome do réu no rol de culpados e expeçam-se guia de execução, ofício ao TRE, IIRGD, VEC, certidão de honorários em favor da Dra. Defensora dativa e o quanto mais necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Pirassununga, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA